

1500014-19.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS, imputando-lhe a prática do crimes tipificado no artigo 33 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

1500014-19.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500014-19.2021.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS, imputando-lhe a prática do crimes tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 21h19m, na Estrada Manoel Francisco de Carvalho, nº 500, bairro Vila Batista, cidade de Pedro de Toledo, comarca de Itariri, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) microtubos de cocaína, com peso bruto de 7.9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 5/6, laudo de constatação preliminar de fls. 9/10 e laudo toxicológico definitivo de fls. 136/138, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Narra que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas e, para tanto, trazia consigo o entorpecente acima referido, com destinação ao espúrio comércio. Ocorre que policiais militares que estavam em patrulhamento no local dos fatos avistaram o

denunciado e o declarante Axcel, ambos com atitude suspeita, e decidiram pela abordagem. Nesse momento, ao perceberem a presença dos agentes, ambos tentaram se evadir a pé, dirigindo-se em direções opostas, sendo posteriormente alcançados e abordados. Prontamente, os policiais militares fizeram a revista pessoal, oportunidade que foram encontradas a quantia de R\$ 9,00 reais no bolso da bermuda de ANDRÉ, bem como os 08 (oito) microtubos de cocaína e, quanto a Axcel, foi encontrado tão somente 1 (um) microtubo, sendo então lavrado termo circunstanciado e encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Indagado, Axcel informou que é primo do denunciado e que na data dos fatos comprou dois pinos de cocaína com André, assentando que pagaria no dia seguinte, quando sua esposa chegasse. A natureza da droga apreendida (Cocaína), bem como as circunstâncias da apreensão, somados aos objetos encontrados na abordagem, evidenciam que o denunciado trazia consigo drogas destinadas ao tráfico.

Foi concedida liberdade provisória a ANDRE (fls. 95/96).

Notificado, o réu apresentou defesa (fls. 177/187) e a denúncia foi recebida (fls. 191/193).

Laudo de constatação a fls. 14/15 e laudo toxicológico definitivo a fls. 136.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado diz que estava com a droga para consumo próprio, em verdade estando toda a droga com seu primo, tendo adquirido juntos de terceiro. Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com a valoração na fixação da pena dos maus antecedentes e, em razão deles, o afastamento da figura privilegiada, com regime inicial fechado (fls. 284/287); e a defesa técnica, pela desclassificação do crime para o do artigo 28 (fls. 281/282 e 291/292).

A folha de antecedentes atualizada foi acostada a fls. 57/73 e 247/264 e há certidão de distribuição a fls. 53/56 e 265/267.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria da ação criminosa restaram demonstradas pelas provas pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de cocaína.

Verdade que a quantidade de droga apreendida, consistente em 8 porções com massa líquida de 1,7g, não é incompatível com o destino ao consumo próprio de um usuário da droga.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês referido como um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não

deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga.

Contudo, não é este o único vetor na análise do dolo, que, no caso, era mesmo a entrega a terceiros, conforme atestado pela testemunha, conhecida de ANDRE e que havia acabado de comprar uma ou duas porções da droga com ele, aliás como atestou já ter feito em outra oportunidade.

Com efeito, Axcel, “primo de criação” de ANDRE, disse que o acompanhava, que estava com 5 pinos. Não sabia que ANDRE guardava droga na casa dele, aliás nunca tinha entrado lá. No dia, ANDRE lhe deu um pino para que usasse e portava mais 5 pinos. Estavam na praça e os policiais os enquadraram. Comprou um único pino de ANDRE. Sabia que ANDRE era traficante, aliás o que também era de conhecimento dos policiais. A única opção que tinha era comprar a droga com ele, o único traficante da região na época. Era a primeira vez que comprou pino, mas já havia comprado maconha. Já era usuário de cocaína. Como todo usuário, tinha que ir comprar em Peruíbe, mas ANDRE passou a vender diretamente em Itariri. Portava um único pino naquele dia, comprado de ANDRE. Naquele dia não tinha ainda usado ou fumado qualquer droga e foi até ANDRE para adquirir 1 pino, por 10 “mangos”. Não se recorda de ter adquirido dois pinos naquele dia e nega ter cheirado dentro da casa um deles. Pensando melhor, e lido o depoimento, pode ter cheirado um segundo pino naquele dia, ambos adquiridos de ANDRE. Tem 23 anos e toma conta dos sítios, fazendo bicos; era usuário de drogas há 5 anos, consumindo maconha e cocaína e já tendo experimentado crack. Adquiriu com seu primo ANDRE maconha já há algum tempo, antes da pandemia, por cerca de três vezes.

O policial Rafael Hipolito da Silva disse que se recorda vagamente, tendo ANDRE acabado de vender a droga para um rapaz, um primo dele, quando abordaram. Estava em patrulhamento e perceberam que um dos dois indivíduos tentou esconder algo no bolso e caminharam em direções diferentes. Abordado, Axcel disse ter adquirido a droga de ANDRE e com ele localizaram mais droga. Em um primeiro momento, ANDRE negou a traficância, mas Axcel confirmou. ANDRE já é conhecido no meio como vendedor de drogas. Informalmente, ANDRE sempre negou a traficância. Segundo se lembra, não era muita droga, talvez 7 pinos no total – até porque os traficantes nunca andam com muita, na tentativa de não ser enquadrado no tráfico ou de não perder a droga. Na abordagem, parte da droga estava com ANDRE e parte com Axcel, mas não se recorda exatamente a quantidade que estava com um e com o outro. Não presenciou a comercialização no momento da abordagem, mas apenas a atitude suspeita, escondendo algo nos bolsos quando da passagem dos policiais. Não se lembra quem estaria com dinheiro, mas provavelmente seria ANDRE, que teria acabado de vender.

O policial Douglas da Silva Cabral disse que abordou ANDRE junto com outro indivíduo e localizaram entorpecente com ambos. Antes da abordagem, a equipe conseguiu visualizar ANDRE entregando a droga para outra pessoa, que, questionada, informou ter comprado a droga de ANDRE. O bairro em que se encontravam é conhecido de traficância, mas não a rua em si. Já havia abordado ANDRE em outras datas, uma vez, segundo se recorda, porque ele estaria andando em local de crime de furto à noite. ANDRE nada disse naquele momento. A abordagem se deu de surpresa, ao passarem pela ponte que dá acesso ao bairro, após a visualização da entrega de alguma coisa por ANDRE. Não se recorda do nome do outro indivíduo. Não se recorda da quantidade de droga em poder de um ou de outro, mas não era grande o total. O que chamou a atenção foi a conduta de entregar a droga e a informação do segundo indivíduo de que estaria comprando. Indagado sobre a versão de Axcel de que teria adquirido a droga na casa, o depoente insiste em ter visualizado a entrega da droga, isto é, de um objeto, só depois confirmado se tratar de droga. A abordagem se deu logo após a entrega do objeto recebido por ANDRE, razão de ter ficado bem claro se tratar de entrega da droga.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação

de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. mutatis mutandis HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com o depoimento da testemunha, como se disse, e com as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante. Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

De qualquer modo, no caso, vê-se que o acusado já havia sido condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao caso vertente, nos autos nº 0003942-43.1999.8.26.0562, 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos, crime do art. 157, § 2º, I e II, em 25/04/1999, com trânsito em 03/03/2000 e cumprimento da pena previsto para setembro de 2022; nos autos nº 0000540-83.2007.8.26.0590, 1ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente, crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do art. 333, em 11/01/2007, com trânsito em 27/02/2009 e cumprimento da última pena previsto para agosto de 2020, respectivamente. Há, ainda, condenação inicialmente substituída por restritiva de direitos, aparentemente com conversão, nos autos nº 0001993-42.2003.8.26.0562, 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos, por fato de e com trânsito em 01/12/2004 e cumprimento da pena previsto para setembro de 2024.

Embora por fatos ocorridos já há muito tempo, o acusado não teve extintas as penas impostas há mais de 5 anos, razão de se reconhecer a reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal), antes que meros maus antecedentes. Seja como for, a aplicação da figura privilegiada exige, cumulativamente, que o acusado seja portador de bons antecedentes.

Ilicitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. Deixo de valorar os maus antecedentes, não recepcionada a valoração de inquéritos ou processos sem trânsito em julgado pela presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos do crime do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As circunstâncias, porém, ensejam menor reprovabilidade diante das condições em que havida a apreensão e constatada a atividade de entrega a terceiros. Como se viu, apenas há notícia da entrega para conhecidos, com o porte de pequena quantidade, de forma simplória, escondida no calçado.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas positivamente, diante da pequena quantidade, inferior, até, ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considero favoráveis a conduta social, as circunstâncias do crime a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada

circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem. E a despeito da multirreincidência, considerando a época em que ocorreram os fatos, suficiente para os fins da pena sua consideração na terceira etapa.

Nada a alterar na terceira etapa, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 1000 dias-multa, fixo a pena de multa final em 500 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar ANDRE LUIZ MUNIZ SANTOS à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao

advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Itariri, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA